



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

反不正当竞争法-总论

王杰 凯原法学院

jie.wang@sjtu.edu.cn

内容提要

- 反不正当竞争法与知识产权保护的关系
- 不正当竞争行为的构成要件
- 不正当竞争行为的主体
- 反不正当竞争法的一般条款

现代不正当竞争法发展

1824年，英国司法判例中确认了被称为仿冒行为（**passing-off**）的**侵权行为**。

1850年前后，法国法院在适用《法国民法典》第**1382**条有关**侵权行为**的规范来处理案件时，首先提出了“不正当竞争”的概念。

德国**1896**年的《禁止不正当竞争法》**是世界上第一部反不正当竞争法**。

反不正当竞争法从民法发展而来，是侵权法的特别法

我国的《反不正当竞争法》

- **1993年颁布**
 - 不正当竞争与垄断合一
- **2017年第一次修订**
 - 废除其中反垄断的内容
 - 修订其中不合适的地方，比如商业贿赂
 - 增加互联网不正当竞争行为
 - 提升处罚力度
- **2019年第二次修订**
 - 修改了商业秘密的相关规定

我国的《反不正当竞争法》

- **2025年第三次修订**
- **1. 新增非法数据获取条款**
- **2. 新增恶意交易/反向刷单条款**
- **3. 新增禁止强制平台内经营者低于成本价行为**
- **4. 新增平台经营者对平台内公平竞争秩序的主动管理责任**
- **5. 新增对滥用优势地位行为的规制**
- **6. 扩展商业标识的保护对象**
- **7. 新增设置搜索关键词产生的混淆行为进行规制**

不正当竞争行为的概念

- 法律定义：
 - 第2条：经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。
- 学理定义：
 - 泛指经营者为了争夺市场竞争优势，违反公认的商业惯例和道德，采用欺诈、混淆等经营手段排挤或破坏竞争，扰乱市场经济秩序，并损害其他经营者和消费者利益的竞争行为

反不正当竞争法与知识产权保护

- 反不正当竞争法的内容分为两类：
 - 1、涉及商业标志或者智力成果保护
 - 仿冒混淆、误导性宣传、侵害商业秘密行为
 - 2、维护商业伦理和市场秩序
 - 虚假宣传、商业诋毁、商业贿赂、不正当有奖销售
- 与知识产权保护的关系：
 - 1、存在竞合
 - 2、附加或者兜底保护（冰山与海水的比喻）

法定赔偿仅适用于类知识产权的客体：
500万以下（
仅第一类适用）



反不正当竞争法与知识产权保护

- 附加或兜底保护
- 早期驰名商标的保护
- 商号、商品特有的名称、包装、装潢、域名
- 作品名称
- 商业秘密
- 有限补充保护
- 有关新闻信息使用的两个案例：
 - 1、被告作为传呼机销售商推出sport Trax服务，向客户推送NBA比赛的实时信息（不构成）
 - 2、位于美国西海岸的报社利用东海岸报社报道的时事新闻（构成）

NBA VS 摩托罗拉

- 利用事实数据行为构成盗用的条件：
 - 1) 手机信息需要一定的成本
 - 2) 信息的价值具有高度的时间敏感性
 - 3) 相对原告费力的生产或收集工作，被告对该信息的使用构成搭便车
 - 4) 被告使用该信息直接与原告的产品或服务竞争
 - 5) 被告的行为会损害原告提供产品或服务的积极性，对原告产品或服务的生存或质量造成实质威胁。

福建豹发力

长暂停
短暂停



103

96



苏州肯帝亚

长暂停
短暂停

尼克森

得分 44



尼克森

篮板 11



Q1(26:30)

Q2(26:22)

Q3(22:23)

Q4(29:21)

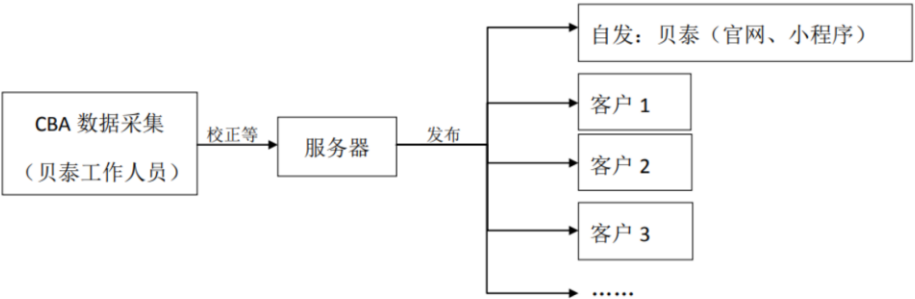


苏州肯帝亚队技术统计

首发球员	位置	首发	得分	投篮 (%)	三分 (%)	罚球 (%)
吴冠希	C	是	23	8-12 (67%)	0-0 (0%)	7-7 (100%)
郑祺龙	PF	是	14	5-10 (50%)	2-4 (50%)	2-3 (66%)
史鸿飞	PG/SG	是	15	5-10 (50%)	5-7 (71%)	0-0 (0%)
德兹-威尔斯	SF	是	18	6-21 (29%)	2-6 (33%)	4-4 (100%)
黄荣奇	SF/SG	是	5	2-10 (20%)	1-5 (20%)	0-0 (0%)
替补球员	位置	首发	得分	投篮 (%)	三分 (%)	罚球 (%)
刘宇轩	PF/C		2	1-1 (100%)	0-0 (0%)	0-0 (0%)
李禄曈	C		0	0-0 (0%)	0-0 (0%)	0-0 (0%)
郭羽舟	PF		0	0-0 (0%)	0-0 (0%)	0-0 (0%)
刘晋廷	PF		0	0-0 (0%)	0-0 (0%)	0-0 (0%)
蒋浩然	PF/C		6	3-7 (43%)	0-2 (0%)	0-0 (0%)

CBA 数据采集及分发示意简图

原告上海贝泰信息技术有限公司提交



反不正当竞争法与知识产权保护

- “晨光笔特有装潢”不正当竞争案（2010）民提字第16号
- 外观设计专利权终止后，该设计并不当然进入公有领域，在符合条件时还可以依据反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的保护。
- 1.该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征。
- 2.通过在市面上的使用，相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来，即该形状构造通过使用获得了第二含义。



最高院：反不正当竞争法可在知识产权之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。

反不正当竞争法与知识产权法保护

- 微信红包案

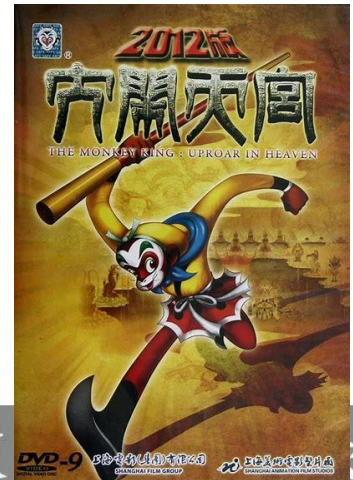


“微信红包”案一审认定涉案“微信红包聊天气泡和开启页”具有独创性，构成美术作品；“微信红包”相关页面构成有一定影响的装潢。认定被告侵害了二原告的信息网络传播权，判令停止侵权并赔偿原告经济损失10万元；认定被告实施了不正当竞争行为，判令停止不正当竞争行为并赔偿腾讯计算机公司经济损失40万元；此外，被告还被判决赔偿原告合理开支9万余元。

反不正当竞争法与知识产权保护

- （2017）最高法院民申4621号
- 被告在“天猫”互联网站内存在名称为“新金旗舰店”的网店，该网店的网页上有“2016猴年贺岁金钞”的商品广告，广告中使用了“美猴王贺岁金”、“源自经典动画《大闹天宫》美猴王形象”，并配有“孙悟空”形象摆出数种动作的美术图案。
- 电影《大闹天宫》于1962年上映。

已过保护期的作品反法不再给予保护



反不正当竞争法与知识产权保护

- 原则：不受知识产权专门法保护的利益（智力成果），反不正当竞争法不保护。
- 例外：产生了与知识产权专门法保护的不同法益
- 如，外观设计经过使用具备识别来源能力
- 反不正当竞争法——行为规制法
- 知识产权专门法——权益保护法



反不正当竞争与知识产权保护

- 当两者冲突时，知识产权具备优先适用性
- 条件：两者保护法益目的相同
- 冲突原因：同一客体上产生不同法益

• 1. 香港荣华诉苏氏荣华

- 苏氏荣华注册了荣华商标，用于糕点等甜品上
- 香港荣华通过使用让荣华月饼成为知名商品名称



(苏氏荣华注册商标)



(香港荣华知名商品特有名称)

最终判决：佛山公司可以仍然使用荣华月饼的名称；但是在使用的时候在外观等方面不得与香港荣华月饼产生混淆

• 2. 重庆诗仙太白酒业诉四川唐朝老窖

- 诗仙拥有知名商品“诗仙太白新花瓷酒”的特有包装装潢
- 唐朝就其生产的“新优诗新花瓷酒”包装装潢申请了外观设计
- 两者的包装装潢类似



特有装潢是为了保护消费者对于商品的识别性；而外观设计保护的是智力成果；因此在这种情况下两者保护的法益不同；因此构成不正当竞争

反不正当竞争法与知识产权保护

- 补充保护的功能（立法漏洞的填补）
- 知识产权——法定之权
- 强调法律规定的确定性，通常以列举的方式规定权利客体、权利范围以及权利限制
- 立法者由于时代或者自身能力的局限，难免有所不周
- 如，修订前的《著作权法》赋予广播组织的权利并不涵盖网络传播，法院以反法来规制盗播的行为。
- 线下转播与网络转播产生的传播效果一致，只是技术手段不同

法定之权，即法律直接规定的；与之相对的是自然权，即没有规定的但天然就有的

在不违背知识产权
立法政策的前提下
提供补充保护。

《反不正当竞争法》的理念

合理的市场环境

经营者消费者的权益

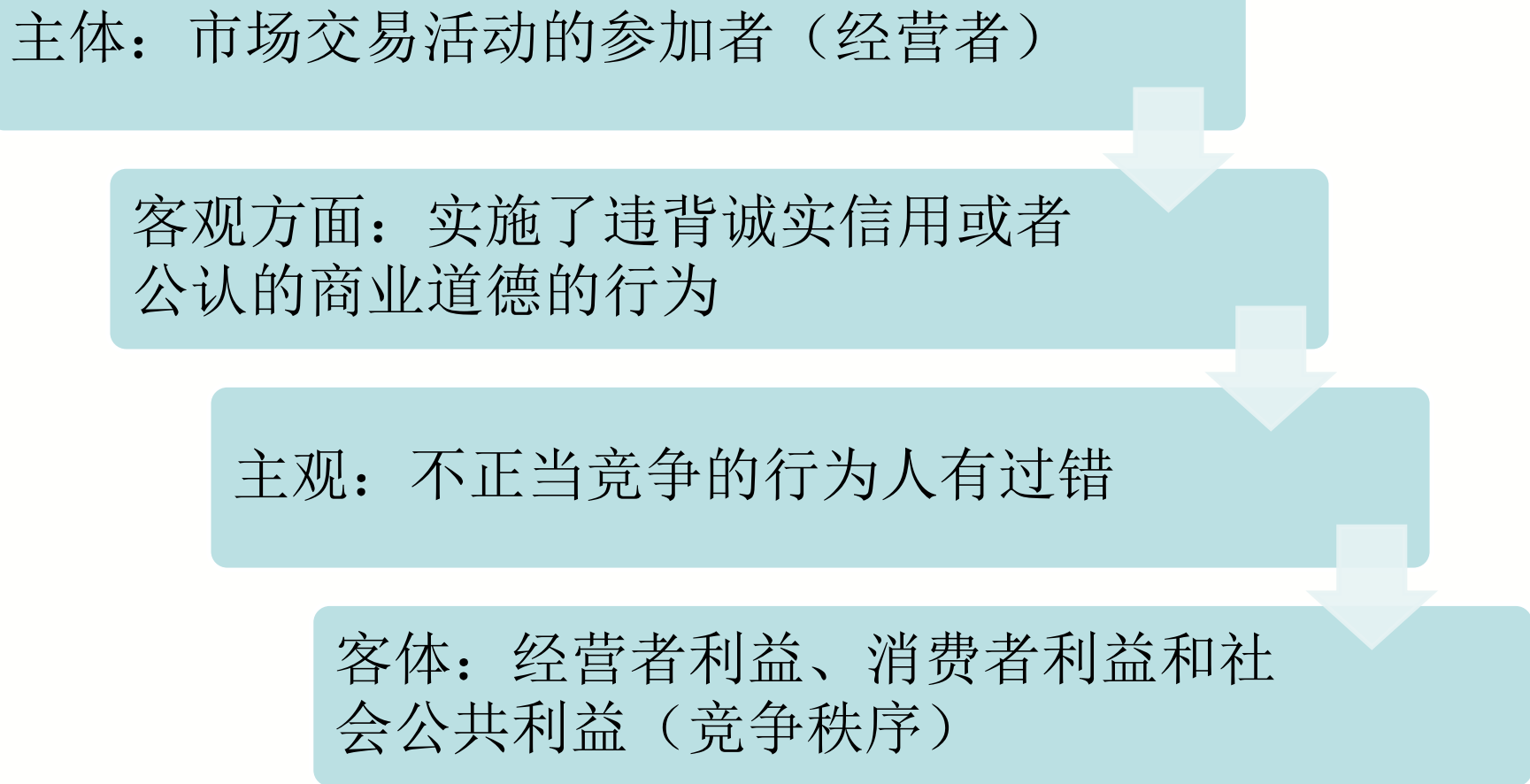
- **公益vs私益：**
- 反法第2条第2款将“扰乱市场竞争秩序”置于保护合法权益之前。
- 意义：在确定新类型不正当竞争行为时，应当首先考虑对竞争秩序的损害，而不是将私益放在首位。
- **效率vs公平：**
- 搭便车等于不正当竞争吗？
- 普通法系：效率优先——动态竞争的保护
- 大陆法系：公平优先——静态竞争的保护
- 中国大陆：效率，如商业模仿要以构成混淆为要件。

虽然侵害了当前的利益，但是有利于整个社会的福利，不构成不正当竞争

只要侵害了当前的利益就构成不正当竞争

不正当竞争行为的构成要件

主体：市场交易活动的参加者（经营者）



```
graph TD; A[主体：市场交易活动的参加者（经营者）] --> B[客观方面：实施了违背诚实信用或者公认的商业道德的行为]; B --> C[主观：不正当竞争的行为人有过错]; C --> D[客体：经营者利益、消费者利益和社会公共利益（竞争秩序）];
```

客观方面：实施了违背诚实信用或者公认的商业道德的行为

主观：不正当竞争的行为人有过错

客体：经营者利益、消费者利益和社会公共利益（竞争秩序）

二、行为（1）

- 实施了违反商业惯例或道德的不正当竞争行为。
- 适用这一构成要件的条件有二个：
 - 惯例或者道德必须是商业的；
 - 惯例或者道德必须是公认的。
- 如何认定？
 - 传统类型
 - 市场混淆（仿冒）
 - 虚假宣传
 - 商业贿赂
 - 侵犯商业秘密
 - 不正当的有奖销售
 - 商业诋毁

商业道德通常比一般道德的要求更高

二、行为（2）

— 新类型

- 从年鉴中搜集相关数据形成的数据库
- 人为改变搜索引擎中的排序
- 模仿其他公司理念制作游戏、节目等等
- 加多宝和王老吉之争
- 内容聚合网站
- 干扰他人软件运行
- 非法爬取他人平台上的数据

三、行为人主体主观上具有过错

- 过错责任
 - 故意
 - 过失
- 过错推定
 - 侵犯商业秘密
- 特殊侵权法

第三十二条 在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。

四、侵犯的客体

- 特定主体的利益
 - 竞争者
 - 消费者（但无诉权）
 - 竞争法与侵权法的交叉
- 不特定主体的利益——竞争利益
 - 竞争法与侵权法的区别
- 如，虚假宣传

五、主观、行为、客体之间的因果关系

- 主观存在从事某种行为的故意或者过失
- 客观上做出了该种行为
- 该行为导致了相应的后果（救济措施的强度）
 - 直接因果关系与损害赔偿计算
 - 侵害特定主体与侵害不特定主体（竞争秩序）



内容提要

- 反不正当竞争行为的构成要件
- 反不正当竞争行为的主体
- 反不正当竞争法的一般条款

法律规定

- 我国《反不正当竞争法》第2条第3款规定：
 - 本法所称的经营者，从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。
- 法律要件
 - 经营商品或者服务
 - 只要经营商品或者服务的都可以吗？
 - 营利性、从事经营性行为（客观标准）
 - 法人、个人或者其他经济组织（组织形式）
 - 隐含要件：侵权人与被侵权人之间的竞争关系或者交易关系（商业诋毁）

三个问题

- 营利性如何界定？
- 组织形式如何理解？
- 竞争关系的范围？

1、关于“营利性”认定

- 正常情况比较容易判定：
 - 腾讯
 - 淘宝
 - 中国移动
- 然而：
 - 非营利组织：学校、医院
 - 行业协会
 - 政府机构

行为角度：
商业行为、竞争行为

(1) 医院

- 医院是否属于经营者？
- 医院以给付“介绍费”、“处方费”等各种名目的费用为手段，诱使其他医院医生介绍病人到本院做CT检查。
- 工商总局在《关于医院给付医生CT“介绍费”等是否构成不正当竞争行为的答复》中明确指出这些行为构成不正当竞争行为。

(2) 高校

- 中国药科大学诉江苏福瑞科技有限公司
- 江苏福瑞公司在其产品“天聪 I 号”胶囊的外包装和宣传单上盗用中国药科大学的名称，没有事实依据地宣称“天聪 I 号”胶囊是中国药科大学的高新科研成果，中国药科大学和福瑞公司携手合作在此领域研究并取得了一系列重大科研成果，“天聪 I 号”胶囊获得中华人民共和国国家发明专利，并假冒专利号。中国药科大学对福瑞公司的虚假宣传提起了诉讼。
- 被告则以原告是**教育事业法人**，不具有提起不正当竞争诉讼的主体资格；原告与被告不存在市场竞争关系等理由抗辩。

什么是事业单位？

- 按照《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定，是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科研、文化等活动的社会服务组织。
- 1998年国务院令第252号发布，2004年修订

原告：

- “第九个五年计划以来，原告已获得卫生部颁发的新药证书70多本，一类新药证书10余本，专利70多项。
- 原告的很多科研成果，都通过附属于原告的中国药科大学制药有限公司、江苏药大医药有限公司、中国药科大学科技实业(集团)总公司、南京药大生物制药有限公司等企业，**转化成医疗器械与众多药品供应市场。**”

南京市中级人民法院

- 原告中国药科大学是从事教学科研工作的事业法人，其虽然不在市场上直接从事商品经营，但**通过附属企业的经营活动**，将其研制开发的药品和医疗器械等推向市场，并且通过附属企业的上缴，间接从市场上获利。
- 附属企业的上缴已经成为中国药科大学的经费来源之一。
- 因此，中国药科大学的市场经营者资格应予确认

(3) 对于协会的不同认定 (a)

- 北京市海淀区人民法院(2005)海民初字第23663号民事判决书：北京中汇文化交流有限公司起诉中国电器工业协会不正当竞争纠纷一案。
- 案情：协会依据法律编订《机电产品目录》。中汇是参与方之一。后来中汇宣称自己被授权编写《电线电缆产品目录》。该行为被协会叫停。中汇起诉。
- 判决：《机电产品目录》是协会在主管机构的授权之下编写的，属于职权范围。中汇没有授权擅自声称授权编写。二者不具有竞争关系，协会不是适格被告。

（2）对于协会的不同认定（b）

- 北京市第一中级人民法院（2006）一中民终字第5251号判决书：艾志工业技术集团有限公司起诉中国摩擦密封材料协会用不正当的竞争行为参与市场竞争
- 案情：协会在宣传某公司的时候声明 —— 是该行业“最好”、“唯一”。竞争者艾志对之进行起诉。
- 法院认为，协会的宣传行为超过了该协会的业务范围，已介入市场竞争，影响了其他竞争者的利益。因此，中国摩擦密封材料协会是《反不正当竞争法》的适格被告。

判断标准：是否在协会权限范围内？

正当进行管理还是参与了市场竞争？

（3）政府机关

- 主体：
 - 浙江省绍兴县运输管理所、人保公司、太平洋保险公司
- 行为：
 - 管理所与两家公司签订协议代为两家保险公司征收“货物运输保险费”
 - 管理所利用运输征管权力，在征收养路费、公路建设基金等规费时，强制车主缴纳本应由车主自愿参加保险的货物运输保险费。
 - 两家保险公司为达到销售其保险服务目的，给付绍兴县运输管理所超过财政部规定最高支付标准的代理手续费、奖励费共计**223570.28元**，绍兴县运输管理所的上述所得均未按财务会计制度规定，明确如实记入法定账目。
- 判决
 - 管理所虽然是法规授权履行交通运输管理职能的事业单位，但当其代理保险业务时，其**从事的不再是根据法律、法规授权的依法征收运输管理费等行政活动，而是以保险代理人身份实施以营利为目的、赚取佣金（保险代理手续费）的民事行为**，与其履行行政职能的征收规费行政行为是两种不同性质的行为。

2、主体的组织形式

- **法人：**符合我国《民法通则》第37条规定的组织
- **个人：**我国《民法通则》第26-27条规定的个体工商户和农村承包经营户；
- **其他经济组织：**我国《宪法》第7、17、42条规定的农村集体经济组织、集体经济组织和城乡集体经济组织。

伍和家诉中孚律师事务所、向阳案

- 原告：伍和家（律师）
- 被告
 - 中孚律师事务所
 - 向阳（中孚律师）
- 案情：中孚律师所及向阳在执业活动中存在虚假宣传及诋毁原告的行为，构成不正当竞争。
- 争点：三者是否适格？

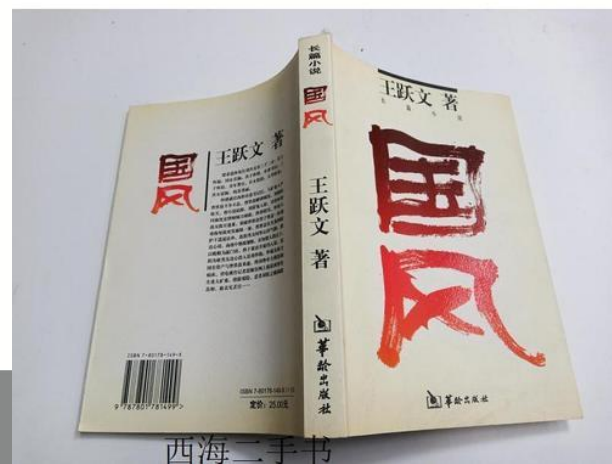
法院判决

- 律师事务所是律师的执业机构，**律师的执业活动必须接受律师事务所的监督管理**；
- 律师事务所按照章程组织律师开展业务工作，**律师承办业务，均由律师事务所统一接受委托**，与委托人签订书面委托合同；律师不得私自接受委托。
- 虽然律师在市场中实际从事法律服务，但是其并不能以自己的名义、作为独立的市场主体提供上述服务。
- 因此，根据本案已经查明的事实，**原告伍和家不属于我国反不正当竞争法所规定的经营者**，其不具有提起本案诉讼的主体资格。同理，被告向阳也不应成为本案被告。
- 驳回了原告的起诉。应当是原告所在律所起诉被告所在的律所

经营者的范围

作家是经营者吗？

参见湖南王跃文诉河北王跃文著作权侵权、不正当竞争纠纷案
(2004)长中民三初字第221号民事判决书



西海二手书

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

法学院

3、竞争关系

- 通常认为，“**竞争法**”是调整具有竞争关系的主体之间的关系的法律。
- 应该如何理解竞争法所调整的竞争关系是一个重要问题。
- 类型
 - 同业竞争关系
 - 不同业呢？
 - 有一种新观点：淡化竞争关系

指出租场地的

电脑商店与电脑商场

饮料公司与日化公司

3Q大战

360扫描电脑文件，建议用户安装360隐私保护器；但是安装后会改变qq功能

- 争点：二者是否属于竞争关系？
- 判决：
 - 第一，从主体的经营范围看，**二者存在业务重合**，拥有相同的市场利益，具有竞争关系
 - 第二，从涉案产品的用户群看，在案中，“**360隐私保护器**”只针对**QQ**软件进行监测，具有唯一针对性，因此“**360隐私保护器**”是依附于**QQ**软件运行，从而**“360隐私保护器”的用户群也是QQ软件的用户群**。由于双方的客户群是同一，从而使得两产品的经营者之间形成竞争关系。

结论

- 最高院的认定方法：

- 在确定市场主体之间竞争关系的时候，不以二者是否属于同一行业或者服务类别为限。
- 如果双方**在生产经营活动中存在可能的争夺交易机会、损害竞争优势等关系的市场主体**，则应当肯定二者之间的竞争关系。
- 类型：
 - 同行业
 - 功能或者用户存在交叉
 - 原被告的下属行业存在竞争关系
 - 潜在的竞争关系

竞争关系判断：

1. 浏览器与视频网站
2. 百度地图与大众点评
3. 百度搜索与搜狗拼音

内容提要

- 反不正当竞争行为的构成要件
- 反不正当竞争行为的主体
- 反不正当竞争法的一般条款

第2条

- 《反不正当竞争法》第2条第1款：
 - “经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。”
 - 直接源于《民法总则》第7条关于诚实信用原则的规定。
- 《反不正当竞争法》第2条第2款：
 - “本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。。”

第2条构建了三叠系的保护目标

非常重要的一页

- 何谓三叠系保护目标？
- 1. 竞争秩序——公共利益
- 2. 竞争者的利益
- 自由竞争、自由发挥经济能力，不受阻碍地提供商品和服务，以利于市场伙伴选择交易对象
- 商业间谍、贬损、模仿导致混淆
- 3. 消费者的利益
- 消费者的自主权不受妨碍，包括不被误导
- 维护竞争秩序是最为重要的保护目标

两种学说

- 法定主义说认为，反不正当竞争法所确定的不正当竞争行为仅限于该法第二章列举的行为，执法、司法机关不得在法律载明的这些行为之外自行认定其他的不正当竞争行为。
 - 传统观点
- 一般条款说认为，反不正当竞争法所调整的不正当竞争行为不限于第二章所列举的行为，还包括根据第二条认定的行为。
 - 现行观点
 - 只能由法院适用

现在已没有争议

分析

- 原则上应当坚持法定主义
- 但是：
 - 市场（主要是科学技术）的快速发展
 - 因此，援用一般原则可以保证《反法》的灵活性。
- 近五年北京法院审判涉网络不正当竞争纠纷案件中，根据一般条款作出判决的比例高达**37%**。
- 但是
 - 在一般条款的指引下，行为的法律后果缺乏可预见性和确定性。
不能由行政执法人员进行
 - 我国执法人员的素质参差不齐（只能由法院适用）。

案例

- 诉讼双方：
 - 原告：金融城公司
 - 被告：财智公司
- 案情：原告在其网站发布原创的“外汇币种走势图”。被告在其网站提供了该走势图的链接，但是通过直接展示的方式实现的（加框链接）。
- 判决：
 - 访问者无法通过该展示方式看到创作者的身份，降低了原告的访问量，侵犯了原告的权益。依据《反不正当竞争法》的一般条款做出了判决。

重要

分析框架

总则分则中都有相关的规制条款的

1、分析是否属于反不正当竞争法中的特别规定；

优先适用特别规定

特别规定是否已经对行为有评价：如请求保护装潢

2、考虑是否与反不正当竞争法作为一项专门法的立法政策产生冲突；

例如，对于现在的互联网巨头，如果爬取了或者利用了它们的数据，得看用途是开发了新的市场还是和原来的数据持有方形成了竞争

例如弹窗广告与广告屏蔽插件的开发者，一般认为这拓展了消费者的福利，同时不影响网站的收益，还促进了广告商以更合适的方式投放广告

维护竞争秩序，推动创新、提升消费者福利

3、确认该行为确实违反诚实信用原则和公认的商业道德；

4、还注意损害特定利益不等于损害相关市场的竞争秩序。

适用需处理好的几个关系

- （一）竞争自由与合同自由、择业自由
- 知名主播跳槽纠纷：斗鱼TV vs 全民TV
- （2017）鄂01民终4950号民事判决书
- 主播朱浩和鱼趣公司签订合同，约定由朱浩**独家**在斗鱼TV上从事游戏解说，合同期限为**5**年，合作费为**400**万。若朱浩违约，需支付年合作费五倍的赔偿金。在合同存续期间，朱浩跳槽去全民TV直播。
- 法院：构成不正当竞争。理由：**存疑案例**，老师不认可判决，认为不构成不正当竞争
- 1、网络直播行业的特点，主播是核心资源
- 2、违反网络直播行业公认的商业道德
- 损害竞争者利益但不提高公共福利
- 3、反不正当竞争法介入的必要性
- 合同法无法提供充分的保护，无法规制挖角的行为

与契约自由的精神相悖

适用需处理好的几个关系

- （二）模仿自由与不正当竞争
- 模仿自由是原则，禁止模仿是例外
- 对于无形的商业成果，由于其公共产品的属性，应当遵循模仿自由的原则。
- 专有权保护是例外，需要特殊的正当性理由。
- 如，版权、专利、商标
- 因此，除知识产权法明确保护的商业成果，原则上因允许他人模仿。
- *模仿是创新的基础，模仿自由是竞争自由的集中体现。
- 模仿刺激创新，降低价格，提升消费者福利

适用时的常见误解

这是朴素的正义感

- “搭便车”、“不劳而获”、“食人而肥” = 不正当竞争

(1997) 高知终字第66号民事判决

虽然涉争对象为金融数据的汇编，虽不能获得著作权保护，但原告对其开发制作付出了投资，承担了投资风险，此种投资产生的利益应受法律保护。被告未经许可获取相关数据并向客户有偿传输，是利用他人劳动成果的搭便车行为，构成不正当竞争。

劳动是获得产权的必要条件但不是充分条件

- 结果：创设了劳动成果权，与著作权的立法政策相冲突
- 应然的分析角度：并非是否利用了他人的劳动成果，而是利用行为是否有害竞争秩序。

正确分析角度：如果不禁止这种行为，那么就会破坏市场秩序，没有人愿意做相应数据的汇编，造成市场相关产品服务不足

反法并非知识产权保护的替代物

第2条的功能

- 1. 总则指导性功能
- 2. 兜底保护的功能
- 列举的不正当竞争行为难以穷尽，可用第2条作为裁判依据
- 对违反诚实信用原则和公认的商业道德的行为予以规制
- 在实践中，以第2条为裁判依据的案件愈来愈多，尤其在互联网领域，技术不断革新、商业模式不断变化

商业道德的理解

- 反法第2条第一款：
- 经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和**商业道德**。

反不正当竞争法第二条规定的“商业道德”，是指特定商业领域**普遍**认可和遵循的行为规范。人民法院应当结合案件具体情况，综合考虑**行业规则或者商业惯例、经营者的主观状态、交易相对人的选择意愿、对市场竞争秩序和消费者知情权、选择权的影响等因素**，依法判断经营者是否违反商业道德。

- 最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释
第三条

商业道德的理解

- 人民法院认定经营者是否违反商业道德时，可以参考：
- 行业主管部门、行业协会或自律组织制定的：从业规范、自律规范
 - 1) 从业规范
 - 2) 自律公约
 - 3) 技术规范，如网络行业
- 商业道德：市场效率基础上的公平、鼓励竞争

QQ V. 360

互联网协会《自律公约》：
软件在安装、运行过程中不得恶意干扰、破坏其他合法软件的正常运行。

消费者利益保护的理解

- 消费者利益是公共利益的重要部分，维护公平竞争的重要目标之一在于提高消费者福利。
- 1. 在进行不正当竞争判定时，应考虑消费者福利的影响。

脉脉从微博爬取了信息，然后用于自己的app,来吸引更多的人进入自己的app

微博诉脉脉案-（2016）京73民终字588号

北知：在判断商业交易中的诚信时，需综合考虑经营者、消费者和社会公众的不同利益，进行利益平衡的考量。本案中脉脉直接从微博抓取用户信息有碍消费者隐私的保护，成为法院认定不正当竞争的依据之一。

- 2. 消费者利益的保护是一种间接保护，消费者没有诉权。
- 根据我国反法，只有经营者有诉权。
- 消费者：举报或依据《消费者权益保护法》

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>